

AUTO NUMERO: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

Córdoba, diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y siete.-

Y VISTOS: Los autos caratulados "**REPOSSI, Juan Carlos p.s.a. Homicidio Culposo -Recurso de Casación**" (Expte. "R", n° 8/96).

DE LOS QUE RESULTA: Por sentencia n° 50, de fecha 8 de Noviembre de 1996, la Cámara en lo Criminal y Correccional de Río Tercero resolvió "...**II**) Rechazar la acción civil resarcitoria ex-delito promovida por Bernardo Bautista Olmos y Miryan Liliana Peralta (fs. 67/69 vta.) y por Héctor Guillermo Castro y Silvia Beatriz Ferreyra (fs. 74/76 vta.), en contra del imputado Juan Carlos Repossi, el civilmente responsable Carlos Alberto Marrone y la citada en garantía, compañía de seguros Cooperación Mutual Patronal Sociedad Mutual de Seguros Generales", imponiendo las costas por el orden causado (arts. 550/551 del C.P.P.)..." (fs. 332).

Y CONSIDERANDO:**I.** Contra la sentencia mencionada recurren en casación -por separado pero en idéntica presentación- los actores civiles Bernardo Bautista Olmos y Miryan Liliana Peralta, por una parte (fs. 344/351) y Héctor Guillermo Castro y Silvia Beatriz Ferreyra por la otra (fs. 335/342).

Atento a la similitud de agravios y fundamentos vertidos, y por razones de brevedad, resulta conveniente el abordaje conjunto de ambos recursos.

1. Si bien el monto total de lo reclamado en conjunto excede las treinta unidades económicas -de las que no se les hizo lugar a importe alguno- igualmente

plantean la inconstitucionalidad del límite objetivo a la procedencia del recurso de casación impuesto por el artículo 473 del C.P.P.. Ello tiene relevancia para el caso en que se entendiera que el agravio es divisible, puesto que de tal modo las sumas a distribuir entre los recurrentes no superan dicho tope (fs. 335 vta. y 344 vta.).

2. Invocando el motivo sustancial previsto en el primer inciso del artículo 468 del C.P.P., sostienen los impugnantes que ha sido inobservado el artículo 1113 del Código Civil, en tanto la sentencia ha declarado inaplicable la presunción de responsabilidad objetiva que aquél establece (fs. 335 y 344).

En el debate, los recurrentes sostuvieron la aplicabilidad de dicha norma, toda vez que la muerte de los menores se produjo por una relación directa con el riesgo de la cosa; ello da lugar a una responsabilidad objetiva del guardián (Repossi) y del dueño (Marrone) del vehículo, que obliga a indemnizar el resultado dañoso producido (fs. 337 y 346 vta.).

Sin embargo, el Tribunal consideró que los elementos determinantes del siniestro fueron: **a)** las ramas colocadas en la calle que rodea la plazoleta, **b)** el juego de los niños en horas de la noche, ya oscuro, y **c)** la falta de vigilancia de los padres respecto de menores de cuatro y siete años de edad. Concluyó, por ende, que debía aplicarse la última parte del segundo párrafo del artículo 1113 del C.C., entendiendo así tácitamente acreditada la culpa de la víctima

o de un tercero por quien no se debe responder (fs. 337 y 346 vta.).

Los recurrentes aclaran que aceptan la absolución de Repossi por inexistencia de culpa penal y también civil (art. 1109, C.C.), pero entienden que los argumentos señalados por el a quo no configuran -ni aisladamente ni en conjunto- la causal de exoneración de responsabilidad objetiva esgrimida (fs. 337 vta. y 346).

Manifiestan que el a quo dudó acerca de si el imputado paró arriba de las ramas por el accidente o porque pensaba estacionar en ese lugar; en materia penal, aplicó el principio de "*in dubbio pro reo*", pero no podía resolver en igual sentido en la cuestión civil (fs. 338/338 vta. y 347/347 vta.).

La infracción de transitar por el carril izquierdo -ya sea para estacionar o para seguir-, en una calle de mano única, dejaba incólume la presunción legal de responsabilidad objetiva, en tanto no se haya demostrado que era imposible avanzar por la derecha (fs. 338 vta. y 347).

Confiesa el fallo, entonces, una falta de certeza en orden a la causa verdadera por la cual el camión transitaba por la izquierda de la mano, y esa falta de certeza tiene que ser soportada por el guardián y el dueño de la cosa riesgosa por expreso imperio de la ley civil, ya que pervive intacta la "causa aparente" (fs. 338 vta. y 347).

Junto con la culpa de los recurrentes por falta de cuidado de los niños y por el depósito de ramas

al costado de la plaza, sobre la calle, debió el a quo hacer concurrir también la culpa proveniente del riesgo de la cosa (fs. 339 y 348 vta.)

No hay entonces, hecho culpable de un tercero ni caso fortuito que quiebre la relación causal: los niños murieron aplastados por el camión y no ahogados por las ramas (fs. 339 y 348 vta.). Las conductas atribuidas a los niños y a sus padres -incluida la colocación de las ramas- no tienen virtualidad suficiente para determinar por sí solas el resultado dañoso; es el riesgo de la cosa el que lleva la mayor parte de la responsabilidad (fs. 340 y 349).

Afirman los impugnantes que desde que la presencia de criaturas jugando en la vía pública es un hecho corriente y general en los pueblos pequeños, los conductores -más aún los de vehículos de gran porte- deben prevenirse extremando su prudencia. La necesidad de pasar por encima de la pila de ramas podadas, ubicadas además sobre la mano izquierda de la calle, no fue acreditada en la sentencia (fs. 340 y 349).

Acreditado entonces el aplastamiento y desvirtuada por los argumentos que preceden la exclusividad del aporte de las víctimas y sus padres al resultado, corresponde hacer funcionar la responsabilidad objetiva del artículo 1113 del C.C. (fs. 340 vta. y 349 vta./350).

Sobre dicha base, los recurrentes gradúan su propia culpa y la de los niños en un treinta por

ciento, y atribuyen solidariamente a Repossi y Marrone la carga del setenta por ciento restante (fs. 341 y vta., y 350 y vta.), haciendo extensivos los efectos de tal declaración a la compañía aseguradora (fs. 341 vta. y 350 vta.).

Desde que los montos peticionados no han sido controvertidos, afirman que el reclamo originario de \$32.200 para cada padre debe ser disminuido según la proporción arriba señalada a \$ 22.540, suma a la que deberán agregarse los intereses devengados desde la fecha del hecho (fs. 341 vta. y 350 vta.).

Solicitan, además, se impongan costas a los demandados, con la reducción del caso.

II. 1. Esta Sala ha declarado la inconstitucionalidad de los límites objetivos establecidos para el recurso de casación (T.S.J., Sala Penal, Sent. n° 17, 20/5/96, "De La Rubia"; Sent. n° 20, 28/5/96, "Gudiño"; A.I. n° 211, 4/11/97, "Grillo"; A.I. n° 28, 16/4/96, "Pérez"; A.I. n° 159, "Maggi"; A.I. n° 211, 4/11/97, entre otros).

Sin embargo, la procedencia del planteo de inconstitucionalidad deducido supone que el escrito recursivo satisfaga -con independencia de la limitación objetiva- las exigencias formales previstas por la ley procesal para la vía impugnativa intentada (T.S.J., Sala Penal, A.I. n° 145, 27/11/96, "Corral"; A.I. n° 13, 19/02/97, "Peralta").

2. Examinado el recurso en cuanto a las demás condiciones requeridas para su procedencia formal, corresponde concluir que el mismo es formalmente inadmisibile por carecer de una

debida fundamentación.

En efecto, el recurso de casación por el **motivo sustancial** procede por la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva (art. 468 inc. 1º, C.P.P.). Lo primero consiste en la no aplicación al resolver el fondo de la cuestión de la regla legal que corresponde; lo segundo, es la inexacta valoración jurídica del caso, ya sea por defecto en la selección o interpretación de la norma (T.S.J., Sala Penal, A.I. n° 202, 28/10/97, "Alvarez"; A.I. n° 170, 1/10/97, "Villena"; cfmes., NUÑEZ, Ricardo C., "Código Procesal Penal", Lerner, Córdoba, 1986, nota 2 al art. 490, pág. 465; DE LA RUA, Fernando, La Casación Penal, Depalma, Bs.As., 1994, pág. 38).

Tanto una como otra hipótesis requieren, como presupuesto ineludible, el respeto de la plataforma fáctica a partir de la cual el *a quo* elabora su solución jurídica, toda vez que de alterarse esta base, se imposibilita el control que se solicita a esta Sala.

Por ello, pacíficamente y desde antiguos precedentes, se ha dicho que a la luz del inciso 1º del artículo 468 del C.P.P., el recurso no procede si se discuten, alteran o ignoran las circunstancias de hecho que tuvo en cuenta el Tribunal de mérito (T.S.J., Sala Penal, 8/8/41, "Brizzio"; A.I. n° 12, 13/3/96, "Bustamante"; A.I. 34, 2/5/96, "Ahumada"; A.I. 37, 7/5/96, "Sarmiento"; A.I. 39, 8/5/96, "De La Rubia"; A.I. 49, 28/5/96, "Medina"; A.I. n° 45, 23/05/96, "Torres"; A.I. N° 107, 17/10/96, "Oviedo"; A.I. n° 109, 21/10/96, "Guerrero Leyria"; A.I. n° 120, 4/11/96,

"López", entre otros; cfmes., DE LA RUA, ob.cit., págs.40 y ss; NUÑEZ, ob.cit., nota 2 al artículo 490, pág. 466).

Ello, sin embargo, es lo que ocurre en el caso, ya que de la lectura de la fundamentación del rechazo de la pretensión civil por parte del sentenciante, puede observarse que la interpretación señalada por los impugnantes como correcta e inobservada no dista de la asumida por aquel como marco teórico: la consecuencia, sin embargo, difiere toda vez que parten de plataformas fácticas diferentes.

En efecto, los recurrentes -so pretexto de inobservancia de la ley sustantiva- pretenden variar la relación causal establecida en forma inamovible por el Tribunal. Éste ha fijado dicho nexo atribuyendo el doble resultado mortal a tres factores: "*...las ramas colocadas por Olmos en el espacio público, en la calle que rodea a la plazoleta Las Heras... el juego de los niños que resultaron víctimas en el siniestro, que lo hacían en horas de la noche cuando ya estaba oscuro, y el tercer elemento... determinante para que la tragedia sucediera, la falta de vigilancia de los padres respecto a menores de cuatro y siete años de edad...*" (fs. 329).

A partir de dichos extremos, aplica la exención de responsabilidad de la última parte del segundo párrafo del artículo 1113, ya que "*...los padres han incumplido los deberes que le imponen los arts. 264 y 265 del C.C....*" (fs. 329).

Más abajo expresa el *a quo* que entre el pisamiento de las ramas en la calle pública, por parte de

Repossi, y la muerte de los menores, se ha roto la relación de causalidad, ya que "...Juan Carlos Repossi, en virtud del art. 1 de la Ley 13.893 de tránsito tenía derecho a transitar por las calles y caminos de la República, y fue precisamente Olmos quien impuso un obstáculo a la circulación que luego se volvió trágicamente en contra de los intereses de sus hijos... es evidente que no se puede llegar desde haber pisado unas ramas al aplastamiento de los menores que jugaban debajo de ellas y que (Repossi) no pudo percibir..." (fs. 329 vta.).

De este modo, y conforme la prueba valorada (pericia oficial, fs. 239/245), resulta también un hecho fijado por el sentenciante la licitud de la maniobra del chofer del camión, junto con la circunstancia de que, en definitiva, el único obstáculo a la circulación en el lugar eran las ramas allí depositadas por Olmos.

Es menester recordar, entonces, que la cuestión relativa al presupuesto fáctico del nexo causal es una cuestión de hecho (T.S.J., Sala Penal, 11/12/68, "Alonso"; A.I. 12, 8/3/96, "Bustamante"; A.I. n° 23, 28/3/96, "Isoardi", entre otros), y desde que ha sido dada por acreditada en estos términos, a ellos debieron atenerse los impugnantes si su pretensión era sustentar la inobservancia de la regla de responsabilidad objetiva del artículo 1113 del C.C..

Alegar la supuesta intervención concurrente -y jurídicamente relevante- del accionar de Repossi a bordo de su camión, en orden al eslabonamiento y relevancia causal de los sucesos, importa una clara

modificación de la plataforma fáctica de la sentencia.

Por más que se alegue la inobservancia de la ley civil, en verdad lo que se pretende es la alteración del hecho a los fines de introducir una causa más -la conducción irregular del imputado- a la que la sentencia no sólo le ha restado eficacia causal, sino que además ha valorado como lícita, dejando, tal como los mismos impugnantes lo admiten, "*...tácitamente acreditada la culpa de la víctima o de un tercero por quien no se debe responder...*" (fs. 337 y 346 vta.; léase, los padres y los niños).

III. Atento a los fundamentos que preceden, corresponde declarar formalmente inadmisibile el recurso de casación deducido por los actores civiles, con costas (arts. 455, segundo párrafo, en función del 474 y 449; 550 y 551, C.P.P.).

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Justicia, por intermedio de la Sala Penal,

RESUELVE: Declarar la inadmisibilidad formal del recurso deducido por los actores civiles Bernardo Bautista Olmos y Miryan Liliana Peralta por una parte, y Héctor Guillermo Castro y Silvia Beatriz Ferreyra por la otra, con costas.

PROTOCOLICESE, HAGASE SABER Y OPORTUNAMENTE BAJEN.-